

1502953-45.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Justiça: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Jardim Francisco Morato, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502953-45.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325811/2021 - DEL.POL.CAIEIRAS, 21694852 - DEL.POL.CAIEIRAS, 2170/21/202 - DEL.POL.CAIEIRAS, 2325811 - DEL.POL.CAIEIRAS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

DANILO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

07/03/2022

Réu Preso

Em 07/03/2022, nesta cidade de Francisco Morato, na sala de audiências do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Francisco Morato, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dra. Renata Marques de Jesus, comigo escrevente abaixo assinado. Presente representante do Ministério Público Dra. Maria Isabel El Maerrawi, foi aberta audiência de instrução e interrogatório, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: o réu DANILO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, acompanhado por advogada constituída, Dra. Maria de Fatima Pereira Taddeo, que realizou reunião privada (item 8.1, do Comunicado CG 284/2020). Presente(s) a(s) testemunha(s) Neilson de Lima Santos e Aparecido de Oliveira Carmo, a(s) qual(is) foi(ram) ouvida(s). Terminada a(s) inquirição(ões), foi colhido o interrogatório do(s) réu(s). O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) através do Microsoft Teams, arquivado(s) na plataforma One Drive e não será(ão) transcrito(s) em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de

documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito: Considerando que as partes não postularam novas diligências, declaro encerrada a instrução. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para alegações finais, seguido pela Defesa. Pelo Ministério Público foi dito: "MM. Juiz(a), DANILO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Americana, altura do número 187, bairro Residencial Casa Grande II, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, guardava, para fins de comercialização, drogas e insumos destinados à preparação de drogas destinadas à comercialização, substâncias proscritas no Brasil, nos termos da Portaria n. 344/98 - SVS/MS, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Custódia (fls. 43/45). Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 82) e ofertou defesa prévia (fls. 86/100). O Ministério Público pleiteou a rejeição das nulidades arguidas pela Defesa (fls. 108/110), o que foi feito pela r. decisão de fls. 111/114, que também recebeu a denúncia em 04 de fevereiro de 2022. A instrução processual desenvolveu-se de forma regular com a oitiva das testemunhas arroladas, ao que se seguiu o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução nesta data, tenho que a ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudos de fls. 139/140 (simulacro de arma de fogo); fls. 141/143 (balanças de precisão); fls. 144/146 (faca); fls. 147/150 (peneira e bacia) e fls. 161/164 (químico-toxicológico). A autoria do crime também é certa e recai sobre o acusado. Segundo apurado, DANILO JOSÉ realizava tráfico de entorpecentes uma casa abandonada, situada no bairro Casa Grande II, em Francisco Morato. Após denúncia anônima, policiais civis se dirigiram ao local indicado acima e visualizaram uma residência com o portão aberto, em aparente situação de abandono. Os policiais, então, ingressaram na residência, ocasião em que encontraram DANILO JOSÉ e uma elevada quantidade de drogas e insumos destinados à produção das porções de entorpecentes destinadas à venda, a saber: 03 porções da substância entorpecente skunk (aproximadamente 250 gramas) e 2.635 porções de substância entorpecente cocaína (aproximadamente 1.280 gramas). Além disso, também foram localizadas e apreendidas 02 balanças de precisão, 01 simulacro de arma de fogo, elevada quantia em dinheiro, 20 quilos de pó branco de cafeína Anidra, 1.300 gramas de pó branco de bicabornato, 1.100 gramas de pó branco (não identificado) para misturar a cocaína e vários recipientes para embalagem da droga. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, denotam o envolvimento do denunciado com a traficância. O crime foi cometido durante o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19. Em Juízo, os policiais civis Neilson de Lima Santos e Aparecido de Oliveira Carmo, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, confirmaram a dinâmica dos fatos, acima descrita, e seus depoimentos perante a autoridade policial (fls. 07 e 08). Relataram que receberam denúncia que indicava que, na cidade de Francisco Morato, no interior de uma casa que estaria abandonada, estaria sendo armazenada grande quantidade de entorpecentes, os quais seriam distribuídos na região e, principalmente, na cidade de Caieiras. Diante disso, foram até o local e verificaram tratar-se de imóvel aberto, em aparente estado de abandono. Ingressaram no imóvel e, prontamente, avistaram DANILO JOSÉ e uma elevada quantidade de entorpecentes espalhados pela sala. Em busca pelo local, encontraram mais drogas, duas balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola e dinheiro, além de substâncias utilizadas para o preparo das porções e recipientes para embalagem de entorpecentes. O policial Neilson, ouvido em Juízo, disse que a casa não tinha móveis e o DANILO JOSÉ estava no interior, dormindo. As drogas estavam no cômodo ao lado ao que ele estava. A casa não parecia habitável. DANILO JOSÉ permaneceu em silêncio durante a abordagem e nada disse sobre as drogas. Não havia mais ninguém no local. Além dos entorpecentes, no local havia um simulacro de arma de fogo e bastante entorpecente, cocaína e skunk, substâncias para refino e acessórios, como balança de precisão e embalagens. Algumas porções já

estavam prontas e embaladas. Às perguntas da Defesa, esclareceu que o cômodo em que DANILO JOSÉ estava e o que as drogas estavam guardadas pertenciam ao mesmo imóvel. O portão e a porta estavam abertos. O policial Aparecido prestou depoimento em sentido semelhante ao de seu colega. Esclareceu que a denúncia dizia que o imóvel parecia inabitado, mas apresentava movimentação típica do tráfico. DANILO JOSÉ dormia sozinho em um cômodo e as drogas estavam na sala. Além das drogas, encontraram insumos para mistura e preparo das porções. DANILO JOSÉ permaneceu em silêncio. A denúncia indicava o local, mas não apontava o nome do responsável. Perante a d. autoridade policial, DANILO JOSÉ permaneceu em silêncio (fls. 12). Em Juízo, disse que, realmente, estava no local. Não morava lá, mas ia até a casa para guardar as drogas. Fazia isso há duas ou três semanas. Sempre trabalhou registrado, mas foi mandado embora em 2019 e não conseguiu mais emprego. Tem três filhos e seu pai faleceu recentemente. Aceitou o "serviço" por dificuldades financeiras. Tal é o panorama probatório dos autos, que permite a condenação do acusado. E isso porque a versão acusatória foi corroborada pelo depoimento dos policiais ouvidos em Juízo e pela confissão do acusado, que alegou ter aceitado trabalhar para o tráfico em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, já que perdeu o emprego e tem filhas e mãe que dependem dele. Firmadas, assim, a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime, de rigor a condenação do acusado. Com relação à DOSIMETRIA DA PENA, anoto que o acusado, à época dos fatos, era maior de 21 anos. O réu confessou os fatos a ele imputados. O crime foi cometido durante estado de calamidade pública, na forma do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Na forma do artigo 42, da Lei de Drogas, a pena-base deve ser incrementada em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder do acusado, de elevado efeito viciante e nefastas consequências sociais. Trata-se de réu primário. O regime inicial de cumprimento da pena, de qualquer modo, deverá ser o fechado, em razão da natureza hedionda do crime, ficando vedada a substituição da pena privativa de liberdade. Ante o exposto, pugno pela condenação do acusado nos termos da denúncia, observando-se os critérios acima para fixação da pena". Pela Defesa foram apresentadas alegações finais orais. As alegações finais foram gravadas através do Microsoft Teams, arquivadas na plataforma One Drive e não serão transcritos em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Em seguida foi proferida a sentença pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito: "Vistos. DANILO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e § 1º, III, da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, 'j', do Código Penal, porque no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Americana, altura do número 187, bairro Residencial Casa Grande II, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, guardava, para fins de comercialização, drogas e insumos destinados à preparação de drogas destinadas à comercialização, substâncias proscritas no Brasil, nos termos da Portaria n. 344/98 - SVS/MS, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 3/5). Em audiência de custódia foi convertida em preventiva a prisão em flagrante (fls. 43/45). Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 86/100) e a denúncia foi recebida (fls. 111/114). Citação às fls. 137/138. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado. Mídia arquivada. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, com aumento de pena base e início de cumprimento de pena no regime fechado. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante, o afastamento da agravante da calamidade e a diminuição da pena nos termos do § 4º, do artigo 33, da lei nº 11343, com regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar. A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudos de constatação provisória (fls. 22/33), laudos de objeto (fls. 139/150), além dos exames químico-toxicológicos de fls. 161/164, que constatarem as presenças de tetrahidrocannabinol (THC), cocaína e

cafeína nas amostras analisadas. A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão. Durante a fase extrajudicial o réu permaneceu em silêncio (fls. 12). Em juízo, por sua vez, declarou ter 30 anos de idade e estava no local. Não morava no local. Ia apenas para guardar as drogas. Fazia esse trabalho há cerca de 2 a 3 semanas. Não conhece as testemunhas, sempre trabalhou registrado, mas foi mandado embora em 2019, tem três filhas menores e recebeu o convite, que aceitou por questão financeira. Nunca foi preso ou processado criminalmente. A testemunha Neilson de Lima Santos, policial civil que participou da ocorrência, narrou que receberam denúncia de uma casa em Francisco Morato que possivelmente armazenava e traficava drogas para Caieiras. A casa era estranha. Fizeram breve campanha. O portão estava aberto. Ele dormia num cômodo e as drogas estavam em um cômodo ao lado. Não pode dizer se ele morava ali ou não. O réu, que não conhecia, nada disse. Ninguém mais estava no local. O réu disse que tinha um simulacro na parte de baixo da casa. As drogas e o acusado estavam na parte de cima. Tinha bastante droga, mas não se recordou da quantidade. Tinha cocaína, maconha, outras químicas para refinar, cafeína, balança de precisão, saquinhos e drogas já embaladas. Esclareceu que o réu e as drogas estavam numa mesma casa. O portão e a porta da casa estavam abertos. Acharam estranho e entraram. A corroborar, o também policial civil Aparecido de Oliveira Carmo relatou que receberam denúncia e se deslocaram ao local. A denúncia dizia que a casa era abandonada, mas tinha movimentação. O portão e a porta estavam abertos. Era um sobrado e na parte de baixo não tinha ninguém. Na parte de cima o réu dormia em um quarto e no cômodo ao lado, uma sala, drogas. Ninguém mais estava no local. Localizaram cocaína, maconha, mistura, petrechos para distribuição. O acusado nada disse. A denúncia não trazia nome de ninguém. É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais civis não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade: “É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011); “O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586); “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189); “Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275); “Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase

policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407). A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório. E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais civis teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido: "PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78). É preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos. Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, corroborando a própria confissão, levando à certeza da autoria. Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, corroborado pela própria confissão, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião. Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em "guardar" as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco). No mesmo sentido: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542); "Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia). Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06): "DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade

- Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09). E o fato de o acusado eventualmente afirmar que é usuário de droga, o que não se

vislumbra, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante: "(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498); "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9.<sup>a</sup> Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016); "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104). Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio. Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, "caput" e § 1º, III, da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena: Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado.(...) 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017). O réu é primário (fls. 42) e não possui antecedentes criminais, contudo, na hipótese, foi localizado com cocaína, entorpecente de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitativa daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício. Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo

magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378). No mesmo sentido, defende Ricardo Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787). Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, verifico presentes as circunstâncias atenuante da confissão (artigo 65, III, "d", do Código Penal) e agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretado o estado de calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância. A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos. Referidas circunstâncias, todavia, devem ser compensadas, mantendo-se a reprimenda no patamar anterior. Na terceira fase não é o caso de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de "tráfico privilegiado". Restou demonstrado que o réu trazia consigo elevada quantidade de entorpecentes (mais de 1,5 quilo de drogas - fls. 9/10), além de petrechos relacionados ao armazenamento, embalagem e distribuição, a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, não demonstrou o exercício de atividade lícita, quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas. Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, valendo trazer à colação, como já se decidiu, que a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010). Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em

organização

criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC 499936 Rel. Min. Jorge Mussi julg. 25/06/2019 publ. 01/07/2019). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (Quinta Turma, AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020). Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição. O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado. Além disso, não se pode olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado: "TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal; AP 0057527-71.2011.8.26.0050; Relator Marco Antonio Marques da Silva, data do julgamento: 27/06/2013). Vale lembrar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (HC 111.840/ES), a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante. E, não sendo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme justificado, não há que se falar em aplicação da determinação proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), que determinou a fixação do regime aberto em relação aos presos que "se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado)", estabelecendo, dentre outras determinações, que "aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena" (grifo nosso). As condições pessoais do réu não são idênticas às daqueles para os quais se determinou a concessão de regime inicial aberto, não se mostrando socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, III, do Código Penal). Ainda que assim não fosse, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, somando um total líquido aproximado de 1.530g, o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013): "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO

ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos. Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez. Pelo mesmo motivo e diante da persistência dos requisitos que mantiveram a prisão cautelar durante o curso do processo, o acusado não poderá recorrer em liberdade. Assim, deverá manter-se recolhido para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão em que se encontra, bem como guia de recolhimento provisória, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo da Execução competente. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar DANILO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e § 1º, III, da lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Em observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o réu encontra-se preso preventivamente a pouco mais de três meses, contudo, não há elementos nos autos - principalmente os subjetivos - para eventual colocação em regime mais benéfico, que fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais, a ele competindo proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da Lei nº 7.210/84: "Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des.Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Com efeito, como acima fundamentado, respondeu ao processo preso, sendo certo que persistem e nesta sentença são reforçados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 9/10), pois decorrente da prática do crime em questão. Observe-se o depósito às fls. 65. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais: "o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá

ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson

Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." - grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib). Oficie-se à OAB local para o cancelamento da nomeação de fls. 83. Sem expedição de honorários porquanto a n.patrona não praticou qualquer ato processual, considerando que o réu constituiu patrona às fls. 101. Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias." Pelo Ministério Público foi dito não ter interesse em recorrer. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado para a acusação. A Defesa manifestou interesse em recorrer da sentença. Assim, recebo o Recurso interposto, devendo a i. Defesa apresentar as razões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Geziel Gomes Barbosa, Escrevente Téc. Judiciário, subscrevi.

MM. Juiz(a) de Direito:

Promotoria de Justiça:

Réu:

Defesa:

Certifico e dou fé que o presente termo foi lido e achado conforme pelas partes presentes e por seus procuradores, os quais saem intimados de seu inteiro termo nada tendo a opor quanto ao seu conteúdo. Certifico ainda que, havendo sido presente o termo assinado eletronicamente pelo(a) MM.(a). Juiz(a) que à mesma presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, Geziel Gomes Barbosa, digitei.